

1502570-87.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... embalagens do tipo ziplock, apetrechos utilizados no tráfico reiterado de entorpecentes.

Como se observa, ainda que as denúncias anônimas sejam provas indiciárias, quando corroboradas por outras provas dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502570-87.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502570-87.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3062675/2021 - DEL.SEC.OURINHOS

PLANTÃO, 19319256 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO PORFIRO SUNELAITES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

TIAGO PORFIRO SUNELAITES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que no dia 30 de julho de 2021, por volta das 02h15min, na Rua João Maria Camargo, n.º 423, Vila Musa, nesta cidade e comarca de Ourinhos-SP, o réu trazia

consigo, para fins de tráfico, 01 porção de cocaína, com massa líquida de 3,85 gramas, bem como guardava, também para fins de tráfico, 07 pedras de "crack", com massa líquida total de 6,48 gramas, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi citado (certidão de fl. 63) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fl. 96).

A decisão de fls. 99/100 recebeu a denúncia no dia 16 de novembro de 2021. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi declarado revel.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia, bem como a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas a ensejar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação requereu pela desclassificação da conduta do réu do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado TIAGO PORFIRO SUNELAITES, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, fotografias de fls. 12/15, laudo de constatação provisória de fls. 17/18 conjugado com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 80/90, sem deixar de mencionar a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, o policial militar Marcio Bernardes declarou que "na data de hoje, realizava o patrulhamento na companhia do colega de serviço, Cb PM Godoi, pelo bairro da Vila Musa, quando adentraram a Rua João Maria Camargo e avistaram o autor Tiago fazendo contato com a testemunha Edilson, ambos já conhecidos no meio policial pelo envolvimento com entorpecentes. Ato contínuo, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo localizada em poder do autor Tiago uma embalagem plástica contendo 06 (seis) pedras pequenas de "crack". Em seguida, visualizaram no interior do imóvel improvisado e ocupado pelo autor Tiago um prato contendo 01 (uma) porção de pó branco semelhante a cocaína e 01 (uma) pedra maior de "crack", além de duas lâminas e diversas embalagens do tipo "zip lock". Indagado, o autor Tiago alegou que saiu para atender Edilson, mas negou que estivesse comercializando entorpecentes. Já, em poder de Edilson nada de ilícito foi localizado e o mesmo alegou que parou ali para perguntar se Tiago tinha latinhas para lhe dar, vez que recolhe reciclagem. Diante dos fatos, conduziram tanto o autor Tiago quanto a testemunha Edilson até este Plantão Policial para conhecimento e deliberação da Autoridade Policial presente." (fl. 01).

Em Juízo, o policial militar Márcio declarou que na data dos fatos, pela madrugada, estava em patrulhamento com o Cb PM Godoi e em decorrência de denúncias sobre o

local que estavam ser conhecido como um ponto de tráfico de drogas. As denúncias informavam o nome do réu Tiago, contudo os policiais não conheciam Tiago pessoalmente. O local que o réu reside é um cortiço, tinham informações de que o ponto de venda de drogas ocorria na primeira casa. Nas imediações da residência do réu circulam usuários de drogas, bem como sempre realiza abordagens naquela região. Ao adentrar a Rua João Maria Camargo visualizou Tiago fazendo contato com Edilson, este conhecido nos meios policiais pelo seu vulgo "Dil" e pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, crimes de furto e pelo uso de drogas. Durante a abordagem dos indivíduos, com o réu Tiago foi encontrada seis pedras de "crack" que estavam em sua mão direita e ao ser indagado, respondeu ser usuário. Já com Edilson nada de ilícito foi localizado e ao ser indagado sobre o que estaria fazendo ali naquele horário, respondeu que estava procurando material para a reciclagem e havia perguntado para Tiago se ele não tinha latinhas para dar para ele comercializar. Solicitou apoio policial para acompanhar a abordagem. Esclareceu que o lado de fora da residência do réu, é uma porta de comércio daquelas de "correr para cima". Esta porta estava levantada e deu para ver que naquele local era improvisado um cômodo. Em cima de uma pia havia um prato com um pó branco, um pacote de "zip lock", uma pedra bruta de crack e duas lâminas, tipo "gilete". O réu foi novamente indagado sobre as drogas e disse ser apenas usuário e que costuma juntar reciclagem para Edilson passar buscar. O depoente e o Cb PM Godoi tinham conhecimento de um furto, ocorrido dias antes, de um "tanquinho" e usuários lhe informaram que este "tanquinho" estaria com o réu Tiago. O referido "tanquinho" foi encontrado na residência do réu, o qual era aparentemente novo. O réu foi indagado sobre a origem do "tanquinho" e respondeu ter o comprado pela rede social facebook. Foi perguntado a ele se ele teria a conversa da negociação pelo facebook, mas o réu não respondeu e permaneceu em silêncio. O réu e Edilson foram conduzidos a delegacia. Posteriormente, o "tanquinho" foi devolvido a vítima. Havia denúncias dando conta que o réu e sua esposa traficavam drogas. (fl. 123 - mídia audiovisual)

Na fase extrajudicial, o policial militar Antonio Carlos de Godoi declarou que "corroborar integralmente as informações prestadas pelo colega de serviço Cb PM Bernardes, informando que, na data de hoje, realizavam o patrulhamento pelo bairro da Vila Musa, quando adentraram a Rua João Maria Camargo e avistaram o autor Tiago fazendo contato com a testemunha Edilson, ambos já conhecido no meio policial pelo envolvimento com entorpecentes. Ato contínuo, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo localizada em poder do autor Tiago uma embalagem plástica contendo 06 (seis) pedras pequenas de "crack". Em seguida, visualizaram no interior do imóvel improvisado e ocupado pelo autor Tiago um prato contendo 01 (uma) porção de pó branco semelhante a cocaína e 01 (uma) pedra maior de "crack", além de duas lâminas e diversas embalagens do tipo "zip lock". Indagado, o autor Tiago alegou que saiu para atender Edilson, mas negou que estivesse comercializando entorpecentes. Já, Edilson alegou que parou ali para perguntar se Tiago tinha latinhas para lhe dar, vez que recolhe reciclagem. Diante dos fatos, conduziram tanto o autor Tiago quanto a testemunha Edilson até este Plantão Policial para conhecimento e deliberação da Autoridade Policial presente." (fl. 02).

Em Juízo, o policial militar Antonio Carlos declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento próximo a residência do réu, bem como informou que há denúncias de que a residência do réu é um ponto de venda de drogas. Não conhecia o réu. Sobre os fatos, visualizou a pessoa de Edilson, o qual já é conhecido nos meios policiais por crimes de furto, tráfico de drogas e também por se usuário, conversando com o réu em uma calçada. Abordou Edilson e o réu Tiago, sendo que com este foi localizada seis pedras de "crack" em suas mãos, prontas e embaladas para a venda, já com Edilson nada de ilícito foi encontrado. Indagou Edilson sobre o que estaria fazendo ali e ele respondeu que estava pegando materiais para a reciclagem, como "latinhas". Já o réu alegou ser usuário de drogas. Descreveu o local em que o réu reside como sendo um comércio desativado, em que a porta era ampla e permitia que o depoente visualizasse o interior do cômodo. Assim, avistou na pia da cozinha um prato contendo um pó branco, que foi identificado posteriormente como cocaína, e uma pedra bruta de crack, a qual se fosse fracionada renderia cerca de trinta pedras de crack. Também foi encontrado na residência embalagens plásticas do tipo

“saquinhos de sorvetes”. Havia denúncias de que o réu recebia de usuários produtos de furtos, bem como de que na residência do réu havia um “tanquinho” que tinha sido furtado de uma outra residência no Jardim Itamaraty dias antes. Encontrou o referido tanquinho. O réu e Edilson foram conduzidos a delegacia de polícia. O referido “tanquinho” foi apreendido e posteriormente entregue a vítima. (fl. 123 – mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, o réu Tiago Porfiro Sunelaites declarou que “saiu para atender Edilson, mas negou que estivesse comercializando entorpecentes”. (fl. 07).

O réu não foi localizado no endereço declinado nos autos e por isso foi decretada a sua revelia. (fl. 123).

Estas foram, em resumo, as provas produzidas em cenário judicial, observadas as regras pertinentes ao devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa, e evidenciam a responsabilidade penal do acusado pelo fato descrito com a denúncia.

A negativa do acusado está isolada nos autos. A traficância está bem evidenciada, cristalina.

Os policiais militares narraram que em patrulhamento se depararam com o réu Tiago em frente a sua residência conversando com outro indivíduo. Durante a abordagem, com o réu Tiago foram encontrada seis pedras de “crack” em sua mão direita. Na residência do réu ainda foram encontrados um prato com uma porção de cocaína, uma pedra de “crack”, em estado bruto, embalagens de “zip lock” e duas lâminas. Os policiais informaram que havia informações dando conta de que o réu vendia drogas em sua residência.

Como se vê, os relatos prestados, tanto em juízo quanto na fase policial, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer elementos que permitissem a ilação de que as testemunhas estariam animadas do propósito de incriminar indevidamente o acusado.

Com efeito, a droga apreendida, que o réu trazia consigo, destinava-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer, pela quantidade, natureza e forma que acondicionada a droga, sendo apreendido com o réu 07 (sete) pedras de “crack” – com massa de 6,48 gramas – sendo 06 já embaladas e prontas para a venda e 01 em estado bruto, bem como 01 (uma) porção de cocaína – com massa de 3,85 gramas, bem como pelos apetrechos utilizados no tráfico de drogas, além de prato com resquícios de cocaína, duas lâminas e diversas embalagens do tipo ziplock apetrechos utilizados no tráfico reiterado de entorpecentes, - conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudos de constatação provisória de fls. 16/18, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 80/90; bem como pelos relatos dos policiais militares, que narraram que havia informação de que o réu traficava entorpecentes em sua residência.

Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, terem depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos.” (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016)

“TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o

édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação. Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido. Recurso improvido." (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Anoto que o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

"A prova policial só deve desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo através de regular instrução. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve aquela ser considerada e chamada para em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente nítido e preciso (RJTERGS 150/143-3)" (Julio Frabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., p. 89, Atlas, 2000).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Sobre a destinação da droga, é de se destacar que foram apreendidas com o réu 07 (sete) pedras de "crack" - com massa de 6,48 gramas - parte já embaladas e prontas para a venda e partes em estado bruto, e 01 (uma) porção de cocaína - com massa de 3,85 gramas, além de prato com resquícios de cocaína, duas lâminas e diversas embalagens do tipo ziplock, apetrechos utilizados no tráfico reiterado de entorpecentes - o que conduz à segura conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, pois é cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, é repartida em porções individuais para facilitar o comércio a terceiros.

Nesse sentido:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papéletes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores." (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Nesse interim, a literatura jurídica revelou que usualmente cada porção de maconha equivale a 0,6 grama (STJRHC nº 37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j. 22.10.2013); cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama (STF HC nº 111.247/MG 2ª Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama (STFHC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013).

Com base nestes dados, conclui-se que a quantidade de "crack" apreendida (6,48g) seria suficiente para produzir aproximadamente 64,8 porções individualizadas da droga. Já em relação a quantidade de cocaína apreendida (3,85g) seria o suficiente para produzir aproximadamente 15,4 porções individualizadas da droga.

Ainda, realce-se "que, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida (7,97g) representa, pelo menos, 398 porções "insuportáveis", ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, "Manual de Medicina Legal", 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, "Medicina Legal e Antropologia Forense", 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar o vil comércio" (TJSP - Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator Desembargador COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Quanto às denúncias que recaem sobre o réu, no sentido de que estaria praticando o tráfico de entorpecentes, é certo que isoladamente denúncias anônimas não possuem o condão de condenar alguém, mas aliadas a outros elementos probatórios constituem indícios concretos da prática delitativa, como é o caso dos autos, na qual os policiais encontraram com o acusado 07 (sete) pedras de "crack", com massa líquida de 6,48g, parte fracionada e parte em estado bruto e 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 3,85g, além de prato com resquícios de cocaína, duas lâminas e diversas embalagens do tipo ziplock, apetrechos utilizados no tráfico reiterado de entorpecentes.

Como se observa, ainda que as denúncias anônimas sejam provas indiciárias, quando corroboradas por outras provas dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE DROGAS. AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO APELANTE, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E A POSSE DO RÉU DE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRAM SUA RESPONSABILIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DO CP. QUANTIDADE DOS TÓXICOS APREENDIDOS E PROVA NA HABITUALIDADE NA VENDA E PLANTIO, NÃO AUTORIZAM SUA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO" (TJPR - 4ª C. Criminal - AC 0662493-3 - Siqueira Campos - Rel.: Des. Miguel Pessoa - Unânime - J. 01.07.2010) (destaquei).

"Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público Pedido de Condenação do corréu Thiago. Acolhido Autoria e materialidade comprovadas para ambos os réus Robusto conjunto probatório - Seguros e insuspeitos relatos dos policiais militares que confirmaram: a denúncia anônima dando conta da prática do tráfico de drogas praticado por dois indivíduos, passando, inclusive, as características deles; bem como a confissão informal dos dois acusados - Réu que foi visto dispensando quantia

em dinheiro em notas amassadas - Atitude comum em coautoria na venda espúria, onde um agente é responsável pelas drogas e o outro pelo dinheiro. Pedido da acusação para aumento da pena base - Possibilidade - Quantidade e diversidade de drogas que justificam o acréscimo nesta etapa. Pedido da acusação para afastar a confissão do corréu Vanderson - Possibilidade - Confissão parcial feita com o intuito de excluir a culpabilidade de seu comparsa, e não com o escopo de auxiliar na resolução da ação criminal - Impossibilidade de concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas - Réus reincidentes - Regime fechado é medida necessária - Dado provimento ao recurso ministerial." (Apelação Criminal nº 1501052-47.2018.8.26.0544; 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Freitas Filho, julgamento em 09.10.2019) (destaquei).

Assim, as denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam. Pontuo que se o réu é realmente usuário de drogas, tal circunstância não exclui sua condição de traficante. Ao contrário, reforça-a, pois é comum que o usuário venda drogas para manter seu vício. Aliás, infelizmente esse não é um caminho incomum, ou seja, a prática cotidiana comprova que no mais das vezes o usuário segue o caminho do vício até não poder mantê-lo às suas próprias expensas, e então passa a vender drogas para mantê-lo.

Assim já decidi o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS Tráfico Alegação de ser o acusado usuário de entorpecentes. Irrelevância. Hipótese em que uma conduta não exclui a outra, sendo comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo Recurso improvido." (TJSP. Apelação Criminal n. 1.167.864.3/4 Ibitinga 5ª Câmara Criminal, Relator: Juvenal Duarte 15.05.08 M.V. Voto n. 2.478).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu ser usuário não o desqualifica como traficante.

Portanto, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu TIAGO PORFIRO SUNELAITES, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Passo à aplicação de sua pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, já que traficava cocaína e "crack", drogas conhecidas por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana. Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Sobre a nocividade da cocaína na forma de "crack", transcrevo trecho de julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Oportuno destacar que, em matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma média de cinco óbitos diários. E, "Segundo especialistas, o crack é 'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo uso (...) Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da cocaína, porém muito mais intensos (...)'" (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos, Bookseller, 2001, p. 63)" (RT, 838/571). Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto - período de tempo, "escravo do desejo de consumir o entorpecente". Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de

crack (...) possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v.Toxicologia Forense cit., cap. V, nº 1.3.1, pág. 136)" (TJSP. Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade.

Portanto, essa circunstância (natureza) autoriza a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena base.

Nesse sentido:

1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019.)

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5ª Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.).

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas (natureza das drogas), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.343/06. O réu não registra antecedentes e não há demonstração de seu envolvimento em atividades outras criminosas. Pontuo que a natureza do entorpecente apreendido já foi utilizada na primeira fase para fixar a pena base, motivo pelo qual, em atenção ao Tema 712 do STF, não será utilizada para a dosagem da fração da minorante. Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena. Atentando ao critério do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por preenchidos os requisitos do art. 44, incisos e § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada no



Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária, também em favor de entidade assistencial a ser fixada no juízo da execução, no valor equivalente a um salário-mínimo da data do pagamento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu TIAGO PORFIRO SUNELAITES, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE em entidade a ser determinada no juízo da execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, também em favor de entidade assistencial a ser fixada no juízo da execução, no valor equivalente a um salário-mínimo da data do pagamento. Considerando o regime aberto fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Quanto aos objetos apreendidos nos autos, tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, e por considerá-los imprestáveis, determino o seu encaminhamento para imediata destruição após o trânsito em julgado.

Considerando o que dos autos consta, deixo de condenar o acusado em custas processuais.

A Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Ourinhos, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA